

1500428-59.2020.8.26.0598

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME BECKER ATHERINO

Comarca: Barra Bonita

Foro: Foro de Barra Bonita

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 20/05/2022

... que conhecia o réu anteriormente pelo tráfico; que o réu já tinha corrido das equipes; que as equipes já tinham até conversado com a avó do acusado; que não se recorda se o réu tinha celular no dia dos fatos; que no local o tráfico era corrente e várias pessoas realizavam o tráfico no local; que confirma seu depoimento que foi lido pelo advogado de defesa; que não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barra Bonita

Foro de Barra Bonita

1ª Vara

Praça Dr. Meira, s/nº, Barra Bonita-SP - cep 17340-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500428-59.2020.8.26.0598

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2317275/2020 - DEL.POL.BARRA BONITA, 15314403 - DEL.POL.BARRA BONITA, 1085/20/203 - DEL.POL.BARRA BONITA, 2317275 - DEL.POL.BARRA BONITA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VITOR AUGUSTO MOYA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME BECKER ATHERINO

Vistos.

VITOR AUGUSTO MOYA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, c.c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei n.11.343/06.

Flagrante formalmente em ordem e concedido a liberdade provisória em favor do réu (fls.53/54).

O réu foi notificado à fl.2594 e apresentou defesa prévia às fls.2589/2591.

A denúncia foi recebida em 28/10/2021 (fls.2599/2601).

Não havendo hipótese de absolvição sumária foi designada data para a realização da audiência de Instrução e Julgamento.

Nesta audiência foram ouvidas três testemunhas de acusação, cinco testemunhas de defesa e, ao final, interrogado o réu.

As partes apresentaram suas alegações finais, conforme mídia anexa.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

-Da preliminar de nulidade - inexistência de autorização judicial para acesso ao celular do réu Vitor Augusto Moya.

A defesa técnica do réu VITOR alega, em breve síntese, a nulidade das provas tendo em vista que o desenrolar de toda a persecução penal se deu após a elaboração de extenso Laudo Pericial contendo os dados extraídos do celular pertencente ao réu, e que não teria ocorrido decisão judicial para tanto.

Sem razão, contudo.

Vislumbro que o réu Vitinho, em sede policial, autorizou o acesso ao seu celular, conforme seu interrogatório (fl.10) e, no mesmo sentido, o relatório final elaborado pelo Delegado de Polícia (fl. 2564), no qual relatou a autorização. Se não tivesse fornecido a senha não seria possível acessá-lo. Afirmar que o acusado não deu autorização naquela oportunidade é imputar delito grave ao senhor delegado de polícia sem qualquer embasamento ou fundamento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de ser ilícita a prova obtida da devassa de celular do acusado no momento da prisão em flagrante, sem prévia autorização judicial. No entanto, a ilegalidade é afastada se há autorização do dono do telefone:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ACESSO AOS DADOS ARMAZENADOS EM APARELHO CELULAR APREENDIDO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PERMISSÃO DO ACUSADO. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVAS AUTÔNOMAS. FONTE INDEPENDENTE. APREENSÃO DE ENTORPECENTES. DIVERSIDADE, FRACIONAMENTO E FORMA DE ACONDICIONAMENTO. VALORES EM DINHEIRO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. DOSIMETRIA PENAL. CONDENAÇÕES ANTERIORES. EXASPERAÇÃO DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. BIS IN IDEM. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem, de ofício. II - A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de ser ilícita a prova oriunda do acesso aos dados armazenados no aparelho celular, relativos a mensagens de texto, SMS, conversas por meio de aplicativos (WhatsApp), obtidos diretamente pela polícia no momento da prisão em flagrante, sem prévia autorização judicial. III - In casu, denota-se que os policiais acessaram as conversas telefônicas do aparelho celular do paciente sem autorização judicial, mas com a permissão do acusado, o que, de fato, não configuraria a ilegalidade. (HABEAS CORPUS Nº 537.274 - MG (2019/0297159-6)).

Ademais, o desenrolar da persecução penal não se deu após a elaboração do laudo realizado no celular do acusado, mas sim a partir de sua prisão em flagrante no momento em que vendeu entorpecente a usuário, o que foi presenciado pelos policiais militares. O conteúdo do celular somente veio a corroborar a afirmação de que o acusado praticava o tráfico ilícito de entorpecentes. Dessa forma, ainda que a prova obtida com o acesso de seu telefone fosse declarada ilícita e nula, ela é autônoma às demais provas obtidas nesses autos, de sorte que o seu desentranhamento de nada adiantaria.

Assim sendo, rejeito a preliminar alegada.

Preenchidos os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame de mérito.

Mérito.

Narra a denúncia que no dia 21 de dezembro de 2020, , por volta das 11h, na Rua Antônio Dário, esquina com a Rua José Paulino, nº 237, próximo ao estabelecimento de ensino CEMEI Antônio Osvaldo de Luca, ginásio e campo esportivos, Núcleo Coronel José V. França, nesta cidade e Comarca de Barra Bonita, VITOR AUGUSTO MOYA, vendeu 01 (uma) porções de cocaína na forma de crack, e trazia consigo, guardava e tinha em depósito 20 (vinte) porções de cocaína na forma de crack, com peso líquido total aproximado de 3,72g (três gramas e setenta e dois centigramas), todas para fins de

entrega ao consumo de terceiros, drogas estas que determinam dependências física e psíquica, sem autorização e determinação legal ou regulamentar.

A dinâmica fática do tráfico de entorpecentes restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls.01/03), boletim de ocorrência (fls.14/17), auto de reconhecimento de pessoa (fl.09), auto de exibição/apreensão (fls.18/19), auto de constatação preliminar de substâncias entorpecente (fl.21), fotografias apreensão (fls.23/37), relatório que atesta o local do tráfico (fl.38), laudo definitivo de entorpecentes (fls.93/95), laudo pericial realizado no celular do acusado (fls.105/2555), relatório final (fls.2563/2570), bem como toda a prova oral colhida.

Em fase administrativa, a testemunha de acusação Rodrigo Aparecido Mello Silva, policial militar, disse que "trabalha no patrulhamento ostensivo, juntamente com o colega de farda Patelli e ambos são componentes da viatura policial militar prefixo i-27220. Destaca que colheu diversas informações anônimas, uma vez que os denunciante temem por sua identificação, de que no local dos fatos, ou seja a imediação da confluência das vias Antônio Dário com José Paulino, vários rapazes costumam utilizar do local para a comercialização de entorpecentes. Segundo as informações colhidas, o movimento de comércio ilícito de drogas, ocorre durante o dia todo. Destaca-se que o local indicado é próximo de uma escola e também de um ginásio poliesportivo, os quais são frequentados por crianças e adolescentes. Assim, nesta data, às 11:00 horas, o depoente e seu colega de farda deslocaram-se ao local e visualizaram o exato momento em que Caio Henrique Alves Teodoro, o qual estava com uma bicicleta, parou na esquina e no local dos fatos adquiriu uma porção de crack, junto ao indivíduo identificado como sendo Vitor Augusto Moya. Este, apanhou um objeto no chão e entregou-o ao Caio. Inicialmente foi abordado o Caio Henrique, que tentou dispensar a porção de crack ao solo, que por sinal foi recuperada e apreendida pelo depoente e por seu colega policial militar.

Entretanto, o caio acabou admitindo que comprou-a junto ao Vitor Augusto, pelo preço de dez reais. Assim, o depoente e seu colega foram até o local onde o Vitor estava e o abordaram. Foram feitas buscas naquele local e no solo, próximo ao imóvel de numeral 237 da Rua José Paulino, ou seja muito próximo de onde estava caio. Ali foram localizadas outras cinco porções de crack, todas embaladas, prontas para o comércio tais como a porção de crack que o caio adquiriu. Destaca que caio confirmou que o local onde as porções foram localizadas era o mesmo local onde o Vitor havia apanhado a porção de crack à qual Caio adquiriu. Prosseguindo nas buscas, no campo da Rua Antônio Dário, próximo do banco de reservas, foram localizadas outras 15 porções de crack, todas embaladas de forma igual as embalagens apreendidas e referidas acima e prontas para o comércio ilegal. Em poder de Vitor foi localizada a importância em moeda corrente de oitenta reais, e no chão, próximo a ele havia uma pilha de moedas que totalizaram noventa e cinco centavos. Vitor ao ser questionado sobre os fatos, segundo os policiais militares, confessou que realmente estava praticando o comércio ilegal das porções de crack apreendidas, bem como confirmou que havia vendido uma porção de crack ao caio, pelo preço de dez reais. Vitor também alegou que, não convém informar de quem conseguia as pedras de crack para serem comercializadas, provavelmente temendo por retaliações acaso informe tais fatos. As porções de crack foram apreendidas, totalizando o montante de 21 porções de crack, embaladas em conjunto e que pesaram 11,35 gramas. Foram embaladas em embalagem plástica de número 4183841. Os dois indivíduos, já são conhecidos nos meios policiais por outros envolvimento com ocorrências relacionadas ao tráfico de entorpecentes. Foram utilizadas algemas, uma vez que havia receio de fuga de ambos, autuado e autor dos fatos. O aparelho de telefonia celular de Vitor foi apreendido. Cumpre destacar que o local onde o comércio ilícito de entorpecentes estava ocorrendo é muito próximo de um estabelecimento de ensino, escola pública onde vários jovens e crianças estudam". Em fase investigativa, a testemunha de acusação Adalex Patelli, policial militar, aduziu que "também é policial militar e confirma que nesta data, juntamente com o sargento aparecido, ambos componentes da viatura policial militar prefixo i-27220, deslocaram-se até o local dos fatos pois há diversas informações, anônimas, de que no local dos fatos, ou seja a imediação da confluência das vias Antônio Dário com

José Paulino, ali, vários rapazes costumam utilizar do local para a comercialização de entorpecentes. Conforme as informações colhidas, o movimento de comércio ilícito de drogas, ocorre durante o dia todo. No local indicado, este é muito próximo de uma escola e também de um ginásio poliesportivo, os quais são frequentados por crianças e adolescentes. Nesta data, às 11:00 horas, o depoente e seu colega de farda deslocaram-se ao local e visualizaram o exato momento em que Caio Henrique Alves Teodoro, o qual estava com uma bicicleta, parou na esquina e no local dos fatos adquiriu uma porção de crack, junto ao indivíduo identificado como sendo Vitor Augusto Moya. Este, apanhou um objeto no chão e entregou-o ao Caio. Na sequência foi abordado o Caio Henrique, que tentou dispensar a porção de crack ao solo, que por sinal foi recuperada e apreendida pelo depoente e por seu colega policial militar. Entretanto o Caio acabou admitindo que comprou-a junto ao Vitor Augusto, pelo preço de dez reais. Assim, o depoente e seu colega foram até o local onde o Vitor estava e o abordaram. Foram feitas buscas naquele local e no solo, próximo ao imóvel de numeral 237 da rua José Paulino, ou seja muito próximo de onde estava Caio, neste local foram localizadas outras cinco porções de crack, todas embaladas, prontas para o comércio tais como a porção de crack que o Caio adquiriu. Destaca que Caio confirmou que o local onde as porções foram localizadas era o mesmo local onde o Vitor havia apanhado a porção de crack à qual Caio adquiriu. Prosseguindo nas buscas, no campo da rua Antônio Dário, próximo do banco de reservas, foram localizadas outras 15 porções de crack, todas embaladas de forma igual as embalagens apreendidas e referidas acima e prontas para o comércio ilegal. Em poder de Vitor foi localizada a importância em moeda corrente de oitenta reais, e no chão, próximo a ele havia uma pilha de moedas que totalizaram noventa e cinco centavos. Vitor ao ser questionado sobre os fatos, segundo os policiais militares, confessou que realmente estava praticando o comércio ilegal das porções de crack apreendidas, bem como confirmou que havia vendido uma porção de crack ao Caio, pelo preço de dez reais. Vitor também alegou que, não convém informar de quem conseguia as pedras de crack para serem comercializadas, provavelmente temendo por retaliações acaso informe tais fatos. As porções de crack foram apreendidas, totalizando o montante de 21 porções de crack, embaladas em conjunto e que pesaram 11,35 gramas. Foram embaladas em embalagem plástica de número 4183841. Os dois indivíduos, já são conhecidos nos meios policiais por outros envolvimento com ocorrências relacionadas ao tráfico de entorpecentes. Foram utilizadas algemas, uma vez que havia receio de fuga de ambos, autuado e autor dos fatos. O aparelho de telefonia celular de Vitor foi apreendido. Cumpre destacar que o local onde o comércio ilícito de entorpecentes estava ocorrendo é muito próximo de um estabelecimento de ensino, escola pública".

Em juízo, a testemunha de acusação Rodrigo Aparecido Mello Silva, policial militar, discorreu que já possuíam informações de que ocorria o tráfico no local, Rua José Paulino, próximo a um campo, um ginásio; que foram averiguar; que quando chegaram viram um rapaz se abaixando pegando algo e entregando a um rapaz de bicicleta; que o réu era o rapaz que se abaixou; que Caio era o rapaz da bicicleta; que abordaram as pessoas; que o rapaz da bicicleta dispensou uma pedra de crack; que onde o réu abaixou encontraram mais pedras de crack; que a denúncia dava conta de que eles iam direto no campo; que foram ao campo e encontraram mais drogas; que o local é perto de uma escola; que na esquina só estavam os dois; que o réu tinha dinheiro consigo; que não havia objetos típicos de uso de entorpecente com o réu; que o réu confessou que tinha acabado de vender a droga por dez reais; que Caio disse que acabara de comprar o entorpecente do réu por dez reais; que conhecia o réu anteriormente pelo tráfico; que o réu já tinha corrido das equipes; que as equipes já tinham até conversado com a avó do acusado; que não se recorda se o réu tinha celular no dia dos fatos; que no local o tráfico era corrente e várias pessoas realizavam o tráfico no local; que confirma seu depoimento que foi lido pelo advogado de defesa; que não se recorda como a droga estava embalada, mas se recorda que foram encontrados entorpecentes no campo; que quando falou que a droga estava embalada quis dizer que elas estavam em um saquinho; que viu o acusado pegando as drogas no chão, mas não viu o acusado pegando drogas no campo; que tinham informações que ele ia direto no campo e voltava; que não é só o acusado que faz o tráfico no local,

mas no dia dos fatos somente o réu estava no local.

A testemunha Adalex Pateli, em Juízo, informou que estava em patrulhamento no local e localizaram o réu com um usuário, de nome Caio, que o réu abaixou pegou algo beirando o muro de uma residência e entregou a Caio; que deram ordem de parada a ambos; que o usuário dispensou uma pedra de crack; que o réu confessou que estava no local comercializando drogas e Caio disse que adquiriu uma pedra de crack do réu; que vistoriaram o local onde o réu se abaixou e encontraram cinco pedras de crack; que encontraram dinheiro com o acusado, aproximadamente cinquenta reais; que vistoriaram os locais próximos e no campo encontraram mais quinze porções de crack; que próximo ao local, cerca de trinta a quarenta metros existe uma escola e dez metro um campo de futebol; que não se recorda de ter encontrado celular com o acusado; que as cinco pedras de crack foram encontradas em um portão da residência; que a busca no campo foi feita em razão de haverem denúncias de que as drogas eram deixadas no campo; que o campo fica a cerca dez metros de onde o acusado estava, atravessando a rua, no campo de visão de onde ele se encontrava; que não encontraram objetos típicos de usuários de droga como cachimbo e isqueiro; que somente estavam os dois no local; que há um campo poliesportivo e do outro lado uma parte de recreação para crianças; que conhecia o réu; que já o abordou outras vezes e ele já havia fugido da equipe correndo para sua residência.

Em fase policial, a testemunha de acusação Caio Henrique Alves Teodoro expôs que "estava andando de bicicleta por uma rua que desconhece o nome, porém trata-se de uma esquina, sendo que nas proximidades há um campo de futebol e uma escola. Que avistou a pessoa de Vitor, o qual sempre está pelo local; assim pediu para que ele "vendessem uma" - se referindo a uma pedra de crack - já que se diz ser dependente químico. Que Vitor pegou a droga de um saquinho que estava no solo. Pagou o valor de dez reais pela porção. No momento que já estava na posse da substância, uma viatura da polícia militar aproximou-se, o que o fez sair rapidamente do local com sua bicicleta. Quando eles estavam próximos, lançou a droga ao solo, porém os policiais a encontraram. Os policiais abordaram Vitor e o revistaram. Que presenciou os policiais encontrando a droga no exato local onde Vitor pegou a porção para lhe vender. Em relação campo de futebol, não acompanhou as buscas, logo não sabe dizer onde estavam. Não sabe dizer quantas porções existiam no saquinho plástico onde Vitor pegou o "crack". Declara que "está limpo" há seis meses - se referindo ao uso de substância entorpecentes, porém na data de ontem, em razão de ter brigado com sua esposa, resolveu fazer uso de droga. Que não havia mais nada em seu poder, apenas um aparelho celular, o qual autorizou a vistoria pelos policiais. Que saiu de sua casa, com a quantia exata de dez reais".

O Ministério Público desistiu da testemunha de acusação Caio Henrique Alves Teodoro.

A defesa anexou nas fls. 2680/2684 declarações de antecedentes.

Já o réu Vitor Augusto Moya, em solo policial, afirmou que "está há um ano sem trabalho, logo, quando surgiu uma oportunidade, por questão financeira e desespero, acabou vendendo droga de forma esporádica. Não deseja manifestar onde e de quem pega a droga para vendê-la. Que estava na esquina da rua José Paulino, proximidade de um campo de futebol, quando um sujeito de bicicleta se aproximou e pediu por "crack". Que a droga estava escondida em um saco plástico, o qual estava atrás de uma parede de uma residência. Em relação as demais drogas encontradas em um campinho de futebol, alega que não lhe pertence. Que estava apenas com seis porções, sendo que vendeu quatro para o indivíduo de bicicleta pelo valor de quarenta reais, lhe restando apenas duas porções. Embora tenha acompanhado os policiais encontrando as outras substâncias, nega a propriedade. Fora a droga, os policiais também encontraram oitenta reais em dinheiro, valor fruto da venda de droga, e um aparelho celular. Que a cada 42 pedras de crack que vende, lucra apenas o valor de cento e vinte reais. Permite que seu celular seja averiguado pelos policiais civis".

Nessa audiência, o réu Vitor Augusto Moya afirmou que tem 20 anos; que não é casado; que não tem filhos; que trabalha com bicos quando foi preso como Calheiro; que ganhava por volta mil e quinhentos reais por mês; que estudou até o 1º ano do ensino médio incompleto; que é usuário de drogas; que somente foi processado por

uso de entorpecentes; que tem conhecimento da acusação.

Quanto aos fatos, respondendo exclusivamente às perguntas formuladas pela defesa narrou que estava na esquina e abaixou deu as pedras para Caio e a viatura já estava em cima do depoente; que confessa que vendeu o entorpecente para Caio; que as droga estavam todas soltas; que tinha seis porções de droga consigo; que vendeu quatro porções para Caio; que ficou com duas; que todas as seis pedras estavam soltas; que viu as drogas mostradas na audiência; que não era dono das drogas encontradas em saquinhos; que essas drogas não foram encontradas consigo; que viu a apreensão dessas pedras; que quando estava no carro o policial foi até o banco de reservas, abaixou e pegou as drogas; que não estava tendo aula na escola perto do local por conta da pandemia; que começou a vender drogas pois estava passando necessidades financeiras; que estava com seu celular; que não forneceu a senha para os policiais; que não permitiu que a polícia civil acessasse seu whatsapp; que não permitiu que qualquer pessoa tivesse acesso ao seu celular; que estudou; que não sabe o que significa a palavra averiguado.

Dito isso, tenho que os fatos narrados na denuncia resultaram definitivamente comprovados.

Os policiais foram categóricos em detalhar o momento da abordagem, bem como aonde as drogas estavam localizadas. O acusado confessou parcialmente os fatos, narrando que vendeu quatro pedras de crack a Caio. Por outro lado, ele negou que as drogas encontradas no campo de futebol eram de sua propriedade.

Caio Henrique Alves Teodoro, sendo a pessoa que comprou a droga de Vitor Moya, reconheceu em solo policial Vitor Augusto Moya como sendo a pessoa que lhe vendeu as porções de crack apreendidas (fl.09).

No mesmo sentido, o Laudo pericial realizado no celular de Vitor Augusto Moya demonstrou sua autoria em diversos momentos. Em conversa com Gabriel Gomes (Vulgo "Garbi") à fl.860, Vitor relata que "então, ele pegou 6 por 50 agora comigo", se referindo a venda de entorpecentes. Vitor, "vitinho", em conversa com Nilton Santos Junior (vulgo "Niltinho" à fl.1066, questiona se este "vai ficar na bala hoje", se referindo a ficar no ponto de drogas a prontidão de vendas.

Vitor Augusto Moya em conversa com Nilton Santos Junior à fl.1072, alerta este dizendo que "Seloco você nem viu os bota, ainda bem que eu vi", aduzindo em relação a polícia militar.

Já em conversa com "Gordinho Fonts" à fl.2396, Vitor Augusto Moya relata que "já fiz a moeda do kit e aquela que falta, logo levo aí", ou seja, que já vendeu o "kit" de entorpecentes e iria entregar o dinheiro para "Gordinho". Na mesma conversa à fl.2406, "Vitinho moia" afirma para "Gordinho" que "ainda tem kit" e "Gordinho" responde que "você tem bastante ainda né", se referindo a quantidade de entorpecentes. Em continuação, Vitor diz para "Gordinho" à fl.2408 que "logo da um salve pra mais um kit". À fl. 2376, Vitor diz para "Gordinho" que tem uma viatura andando e pediu para "Gordinho" ir buscar, "vem rápido mano, civil ta andando", logo após isso Vitor relata para "Gordinho" que "Já aproveitei e vendi".

Ainda na conversa com "Gordinho", este diz para Vitor Augusto Moya (vulgo chacinha) que precisa pegar a "moeda" e Vitor pergunta se poderia ser no dia seguinte, pois ainda só tem 290 e vai faltar 10.

Na folha 2363 dos autos, Vitor Augusto Moya relata para "Gordinho" que a "civil ta andando" e que "eles ta aqui na escola". Assim "Gordinho" responde para Vitor tomar cuidado e Vitor respondeu que "saiu do campo e eles nem viu, acho que eles foi pra pegar filmagem".

Em continuação à fl.2341, Vitor pede para "Gordinho" "encostar pegar dinheiro de um kit". À fl. 2346 Vitinho afirma que "eles parou nós, eles ta no campo, tá moiado em" e logo após diz que "vou esperar mais um pouco só e já vou meter marcha denovo", se referindo a voltar às vendas.

Ainda, em consonância, à fl.2333, o acusado discorre para "Gordinho" que "Boa, já vendo o kit. To em casa, vou tomar uma ducha e depois levo a moeda aí", se referindo a venda de entorpecentes e o dinheiro obtido com a traficância.

Novamente, à fl. 2273, o acusado relata para "Gordinho" que já vendeu o seu kit e que "mais logo saiu um 11 por 100".

Por fim, em conversa com "Kaue", o réu questionar "como tá aí? Fez uma moeda já?" e

"Kaue" responde "fiz nada e aí", momento em que o acusado afirma que vendeu apenas uma "perpa" (crack).

Assim, devidamente atestada a autoria do réu quanto à traficância.

Diante das conversas colhidas pelo Laudo pericial, se demonstrou inquestionavelmente que Vitor Augusto Moya se dedicava a entrega de drogas a consumo de terceiro, sendo a sua autoria comprovada. Além disso, por diversas vezes ele relata que está no "campo", local exato aonde foi preso em flagrante e no qual os policiais descreveram idoneamente.

Insta salientar que não há motivos plausíveis para que os policiais faltassem com a verdade e incriminassem injustamente os réus. Nesse sentido coleciono o seguinte julgado:

"Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT 668/275), inclusive porque "o depoimento policial, como elemento de informação judicial, para ser acolhido, deve estar sempre acompanhado e confrontado por outras provas obtidas no curso da instrução processual, formando um todo coerente e logicamente harmônico, designativo da responsabilidade criminal do réu"(TJ/SP - Ap. Criminal nº 102.370-3 - rel. Márcio Bártoli, j. 03.04.91).

No caso em comento, os policiais encontraram Vitor Augusto Moya em atitude direta de venda para Caio Henrique Alves Teodoro. No entanto, não é necessário que o acusado tenha sido em atitude direta de venda ou inexistir qualquer anotação com a contabilidade do tráfico ou dinheiro apreendido nos autos, pois basta a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no artigo 33, caput, da Lei 11343/06, para a configuração do crime, em que o dolo é genérico.

Portanto, não é indispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando o conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato probando) que envolvem o acusado.

"O crime de tráfico de entorpecente é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente" (RT 776/663). "Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido". (RT 729/542).

Ademais, o restante das drogas apreendidas, foram encontradas no mesmo local de onde Vitor retirou as drogas para entregar para Caio, o que demonstra que a droga apreendida era de sua propriedade. Caio inclusive confirmou isso em seu depoimento (Fl.08). Cinco das vinte porções foram encontradas no mesmo lugar que Vitor retirou as drogas para entregar a Caio e o remanescente de 15 porções de cocaína na forma de crack foi localizado em um imóvel muito perto de onde Vitor estava, estando acondicionadas e embaladas da mesma forma que a droga apreendida na posse de Vitor. Assim, considerando a prova dos autos, a localização dos entorpecentes, a quantidade apreendida, a forma que estavam acondicionadas (prontas para o tráfico), assim como os depoimentos das testemunhas e dos policiais que visualizaram a atitude direta de venda, comprovado está que os entorpecentes encontrados na posse do acusado eram destinados ao consumo de terceiros.

Vale ressaltar que, a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XLIII, estabelece que o tráfico de drogas e condutas afins são crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia equiparando-o aos crimes hediondos, demonstrando a gravidade do ilícito penal, bem como a reprovabilidade dessa conduta.

Desta forma, a coligação das provas contidas nos autos - da formação do inquérito policial ao momento de prolação da sentença - encontra-se apta a demonstrar a prática de comercialização de entorpecentes. Afasta-se, pois, qualquer possibilidade concernente à absolvição ou desclassificação.

Necessário ressaltar, por fim, que a causa de aumento de pena prevista no artigo

40, inciso III, da Lei 11.343/06, se aplica ao caso uma vez que a pratica da traficância foi cometida nas imediações de uma escola infantil. Essa causa de aumento de pena pretender dar tratamento mais gravoso aos agentes que pratiquem os crimes dos artigos 33 a 37 da Lei 11.343/06 nas imediações e dependências de locais com maior fluxo de pessoas vulneráveis. É indiscutível que a pratica do trafico perto de uma escola infantil, aonde estudam diversos jovens e crianças, é socialmente mais danosa e merece maior reprovabilidade. O relatório à fl.38 demonstra com exatidão que a pratica do trafico se dava na esquina de uma escola infantil.

Assim, porque comprovada a prática do fato típico, e não verificada a existência de excludentes de ilicitude ou culpabilidade, de rigor a condenação do requerido por infração ao disposto no artigo 33, caput, c.c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei n.11.343/06.

Passo, agora, à dosimetria da pena.

Atento às circunstancias do artigo 59 do Código Penal, assim como aquelas previstas no artigo 42 da Lei 11.343/06, não verifico circunstancias judiciais a serem consideradas na primeira fase da dosimetria. Fixo a pena-base no mínimo legal em 05(cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Não concorrem circunstancias agravantes. Todavia, verifico que o réu, na data dos fatos, era menor de 21 anos, fazendo jus a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal. Além disso, ele confirmou parcialmente os fatos. No entanto, tratando-se da segunda fase do processo dosimétrico, é necessário respeitar as margens de mínimo e máximo legal estabelecidos por lei, de forma que se torna impossível, nesse patamar dosimétrico, diminuir a pena aquém do mínimo legal. Assim, mantenho a pena no mínimo legal, em 05(cinco) anos de reclusão e pagamento de 500(quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena a serem reconhecidas.

Entendo ausentes os requisitos do redutor previsto no 4º, do art. 33, da Lei 11.343./06, uma vez que conforme as investigações e a prova colhida, o réu não se tratava de traficante eventual, se dedicando à traficância. Inclusive, ele já foi condenado nos autos do processo 1500572-52.2021.8.26.0063 pela prática do delito de associação para o tráfico. Destarte, o réu não pode ser tido como um traficante eventual, merecedor do benefício.

Por outro lado, é necessário reconhecer a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, uma vez que a prática do trafico de entorpecentes foi realizada nas mediações de uma escola infantil, campo esportivo e local de recreação. É irrelevante que não se estivesse a ter aulas no estabelecimento de ensino, conforme jurisprudência mais recente do E. Supremo Tribunal Federal. Assim, aumento a pena em 1/3, tendo em vista que se tratava de escola de ensino básico, aonde frequentam crianças de até 06(seis) anos de idade e, ainda, que próximo ao local também havia um campo esportivo e um local de recreação. Assim, a conduta é mais gravosa do que aquela praticada apenas nas proximidades de instituição de ensino. Deste modo, fixo a pena definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Inexistindo elementos suficientes para reconhecer a capacidade financeira do réu, fixo o dia-multa em 1/30 do salário mínimo nacional.

Na forma do artigo 33, § 2º, alínea "a", e § 3º, a pena privativa de liberdade será cumprida em regime inicialmente fechado, porque se trata de crimes graves e de extrema reprovabilidade e que movimenta toda uma estrutura criminosa. A fixação de regime mais brando não seria suficiente para reprimir a prática do delito. O quantum da pena aplicada, bem como a reprovabilidade do delito, impede a fixação de regime mais brando.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito não é cabível na espécie, uma vez que seria insuficiente à prevenção e repressão do ilícito penal (artigo 44, inciso III, do Código Penal). Ademais, diante do quantum da pena aplicada, entendo ausentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal. Ausentes, de igual modo, os requisitos do artigo 77, do Código Penal. Deixo, assim, de conceder o sursis ao apenado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para CONDENAR o réu VITOR AUGUSTO MOYA ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional, por infração ao disposto no artigo 33, caput, c.c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei n.11.343/06.

Como respondeu solto ao presente feito, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade desta sentença, neste processo. Esse benefício não se aplica ao processo 1500572-52.2021.8.26.0063.

Custas pelo condenado, na forma do artigo 4º, § 9º, da Lei nº 11.608/03, ressalvada a gratuidade.

Fixo os honorários advocatícios em 70% da tabela, expedindo-se o necessário desde logo e ficando o restante a ser apreciado quando do trânsito em julgado.

Após o trânsito em julgado, (i) intime-se os réus para o pagamento da pena de multa; (ii) expeça-se a guia de execução definitiva; (iii) expeça-se ofício ao IIRGD e ao TRE.

P.I.C.

Barra Bonita, 20 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA